

1500825-87.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... nesta cidade e comarca, para fins de tráfico, tinha em depósito, trazia consigo e guardava drogas, conforme laudo de constatação provisória (fls. 18/25), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da exordial que o réu decidiu dedicar-se ao tráfico de drogas, razão pela qual dispunha de grande quantidade de drogas para o comércio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500825-87.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500825-87.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2172303/2022 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 25766217 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2172303 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, BOCV1576-1/2022 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN LEONARDO DA CUNHA SOARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

JHONATAN LEONARDO DA CUNHA SOARES, qualificado nos autos às fls. 10, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 21 horas, na Avenida da Fraternidade, próximo da linha do trem, Água Quente, nesta cidade e comarca, para fins de tráfico, tinha em depósito, trazia consigo e guardava drogas, conforme laudo de constatação provisória (fls. 18/25), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da exordial que o réu decidiu dedicar-se ao tráfico de drogas, razão pela qual dispunha de grande quantidade de drogas para o comércio ilícito.

Narra a inicial acusatória que, segundo se apurou, em patrulhamento de rotina, milicianos viram dois indivíduos em atitude suspeita, razão pela qual decidiram se aproximar. Por outro lado, ao perceberam a movimentação da Polícia, os indivíduos se separaram, tendo o réu se livrado de uma sacola, jogando-a ao chão, e saiu correndo, tentando escapar da abordagem policial, enquanto o outro indivíduo permaneceu no local. Os policiais se separaram, tendo um corrido atrás do réu, e o outro abordou a testemunha que permaneceu parada no local.

Versa a denúncia que identificada como Adrian, a testemunha foi revistada e nada de

ilícito foi encontrado em seu poder, razão pela qual foi liberada no local dos fatos. Em seguida, a sacola antes jogada no chão foi apreendida, sendo encontrado em seu interior: 47 eppendorfs de cocaína, 52 buchas de Cannabis Sativa L (maconha) e 64 pedras de crack.

Consta na exordial que, concomitantemente, por telefone, o policial avisou que o réu havia entrado numa igreja. Lá, reunidos novamente, os policiais militares conseguiram abordar o réu, o qual foi identificado como JHONATAN LEONARDO DA CUNHA SOARES. Revistado, foi apreendido R\$ 5,00 em dinheiro. Questionado, o réu confessou a prática do crime, revelando ainda que no banheiro da igreja conseguiu se livrar de mais 10 porções de maconha, jogando-as no vaso sanitário e acionando a descarga. Narra a inicial acusatória que o dolo do tráfico é percebido pela quantidade de substâncias apreendidas, pelas diferentes naturezas entorpecentes, pelo modo de embalagem, pela tentativa de fuga, dentre outras circunstâncias da prisão em flagrante.

Segundo a denúncia, na fase policial, o réu permaneceu calado (fls. 04). Em audiência de custódia, fls. 40/41, negou a prática de violência policial, nada mencionando sobre os fatos.

A prisão em flagrante do réu foi homologada e lhe foi concedida a liberdade provisória (fls. 40/41 e 46/47).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 52/54), o réu foi devidamente notificado (fls. 67/68) e apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 72/73).

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2022 (fls. 74/75) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 111/112).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a condenação, diante das provas colhidas. Salientou que os policiais não conheciam o réu e não teriam porque prejudicá-lo. Atualmente há câmeras em todos os lugares. Havia quantidade e variedade de drogas. Não há porque desacreditar dos policiais. Réu com habitualidade criminosa. Regime inicial fechado.

Já a Defesa requereu a absolvição do réu. Argumentou que o juiz plantonista liberou o réu na audiência de custódia por causa da situação nebulosa. Os policiais não foram convictos. Mais de uma pessoa fugiu do local. Acompanhou o réu em sede policial. O espaço da delegacia é pequeno. O acusado acabou de ser preso e está ao lado do policial que o prendeu. Por isso a opção pelo silêncio. Materialidade comprovada, mas a autoria é incerta. O réu é um usuário de drogas. Estava em biqueira, mas não é um traficante. Requereu a desclassificação para o crime do artigo 28 e em caso de condenação, sustentou que a quantidade não justifica a elevação da pena. Sem agravantes ou atenuantes. Réu primário, possível a redução do privilégio. Recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percursora de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é procedente. Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu cometeu o delito que lhe imputa a inicial acusatória.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/32), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16), pelo laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 18/24), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 26), pelas fotografias do réu (fls. 29), pelo comprovante de depósito judicial da quantia apreendida (fls. 50), pelo laudo do exame químico-toxicológico, que constatou a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nos materiais apreendidos (fls. 123/125) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

A testemunha Fábio, policial militar, ouvido em solo policial (fls. 02), relatou "que efetuava patrulhamento quando, ao entrar em um beco, deparou-se com indivíduos, ocasião em que um deles permaneceu parado, enquanto o outro (indiciado)

dispensou uma sacola plástica e empreendeu fuga atravessando a linha do trem sentido Avenida Fraternidade. O condutor abordou o indivíduo que permaneceu parado no local, enquanto seu parceiro (testemunha WESLEY) partiu no encalço do indiciado. No interior da sacola dispensada foram localizados 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, 52 (cinquenta e duas) buchas de maconha e 64 (sessenta e quatro) pedras de crack. O indivíduo abordado pelo condutor foi identificado como ADRIAN LUCAS DOS SANTOS, RG 57.716.470, ocasião em que foi submetido à revista pessoal, nada de ilícito encontrando em seu poder, tendo ele dito que apenas passava pelo local e que não conhecia o outro indivíduo que havia saído correndo, motivo pelo qual o liberou no próprio local. A testemunha WESLEY avisou ao condutor, por telefone, que o indiciado teria entrado em uma igreja situada na Rua Miguel Abraão Feres, 150, Vila Olímpia. Assim, deslocou-se ao referido templo religioso, onde abordaram o indiciado no banheiro, ocasião em que ele disse ter dispensado dez buchas de maconha no vaso sanitário e acionado a descarga. Naquela oportunidade o indiciado foi submetido à revista pessoal, sendo encontrado em seu poder, no bolso lateral de sua calça, R\$ 5,00 (cinco reais), ocasião em que assumiu a propriedade das drogas localizadas na sacola que havia dispensado. Diante dos fatos deu voz de prisão ao indiciado, feita a leitura dos direitos constitucionais a ele, sendo necessário o uso de algemas por receio de fuga do agente e, após, promovida sua condução a este plantão." (sic).

Em juízo, o policial militar Fabio disse que em local conhecido pelo tráfico de drogas viram dois indivíduos, que ao vê-los fugiram, cada um para um lado. O réu dispensou uma sacola e correu. Escondeu-se numa igreja, no banheiro. Com ele havia uma quantia em dinheiro. Conversando com ele, ele disse que no vaso dispensou algumas porções de maconha. Pegou a sacola que ele dispensou e havia várias porções de maconha embaladas para a venda. Quando ele dispensou a sacola estavam a 5, 10 metros dele. A ação foi visível.

A testemunha Wesley, policial militar, ouvido em solo policial (fls. 03), relatou "que efetuava patrulhamento quando, ao entrar em um beco, deparou-se com dois indivíduos, ocasião em que um deles permaneceu parado, enquanto o outro (indiciado) dispensou uma sacola plástica e empreendeu fuga atravessando a linha do trem sentido Avenida Fraternidade. O condutor abordou o indivíduo que permaneceu parado no local, enquanto o depoente partiu no encalço do indiciado, o qual abrigou-se no interior de uma igreja situada na Rua Miguel Abraão Feres, 150, Vila Olímpia, ocasião em que, por telefone, comunicou o encontro ao seu parceiro, ora condutor. Na sequência, na companhia do condutor, abordaram o indiciado no banheiro, ocasião em que ele disse ter dispensado dez buchas de maconha no vaso sanitário e acionado a descarga. Naquela oportunidade o indiciado foi submetido à revista pessoal, sendo encontrado em seu poder, no bolso lateral de sua calça, R\$ 5,00 (cinco reais), tendo então assumido a propriedade das drogas localizadas na sacola que havia dispensado. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao indiciado, feita a leitura dos direitos constitucionais a ele, sendo necessário o uso de algemas por receio de fuga do agente e, após, promovida sua condução a este plantão." (sic).

Em juízo o policial militar Wesley disse que avistaram dois indivíduos. Ao vê-los, um dele correu dispensando uma sacola. Fizeram o acompanhamento. Ele escondeu-se no banheiro de uma igreja. Ao ser abordado ele informou que dispensou porções de maconha no sanitário. Viu o réu dispensar uma sacola. O policial Fabio pegou a sacola enquanto abordou o réu.

O réu, na delegacia (fls. 04), optou por permanecer em silêncio.

Em audiência de custódia (fls. 40/41), informou que tem 25 anos de idade. Já foi preso como usuário e por receptação, mas não chegou a ser condenado. Não sofreu violência quando da prisão, mas a abordagem foi dura. Trabalha com carteira assinada há um ano, a completar em agosto.

Em juízo, o réu disse que tem 26 anos, é auxiliar de marceneiro há um ano e meio, mas sempre teve barbearia e trabalho. É usuário de maconha. Estava indo em direção ao local do tráfico de drogas. Tinha cinco reais, não chegou a comprar. Entrou no local do tráfico. Pediu a maconha. Os policiais chegaram, os meninos correram cada um para um lado e ficou no local. Não consegue correr, porque sofreu um acidente no ano passado. Tem pinos e uma haste na cintura. Ficaram ele e mais um. Os policiais

queriam saber quem tinha corrido. Não tinha drogas. Foi levado para o lado direito da linha do trem, onde tem a câmara do CÔI. Foi algemado à força, muita hostilidade. Na delegacia apresentaram as drogas. Estava com uniforme de trabalho por baixo. Não entrou em igreja, não correu. Adryan sabe que não correu. Não disseram porque ia preso. Não conhecia os policiais. Não é de abordagem, não tem problema com polícia. Seu pai é segurança de condomínio. Eles queriam quem correu, mas não é do bairro. Não explicou isso para o delegado, porque não teve oportunidade, os policiais estavam lá o tempo todo. Falou apenas para o seu advogado, quando ele chegou, e depois na audiência de custódia. Tem passagem como usuário de maconha e receptação. Também uma venda de DVD pirata. Tem um filho. Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

Os policiais estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando visualizaram dois indivíduos em um beco, posteriormente identificados como sendo o réu e Adrian.

Quando da aproximação da guarnição, o réu dispensou uma sacola plástica e empreendeu fuga.

Adrian, por sua vez, permaneceu no local, foi abordado, e nada de ilícito fora encontrado com ele. Adrian informou que estava apenas passando pelo local e desconhecia o réu.

A sacola dispensada pelo réu foi recolhida pelos policiais e no seu interior havia 47 (quarenta e sete) microtubos contendo cocaína, 52 (cinquenta e duas) porções de maconha e 64 (sessenta e quatro) pedras de crack.

Na fuga, o réu entrou em uma igreja, então os policiais foram até o local e o abordaram, oportunidade em que ele confessou ter dispensado 10 (dez) porções de maconha em um vaso sanitário do local e acionado a descarga. Nada de ilícito fora encontrado com o réu, tão somente a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais).

Formalmente inquirido pela Autoridade Policial, o réu optou por permanecer em silêncio.

Em audiência de custódia informou que não sofreu qualquer agressão durante a abordagem policial.

Em juízo, o réu negou a prática delitativa. Disse que não correu e que estava no local apenas para comprar drogas, o que não chegou a fazer.

Como se pode perceber, os policiais apresentaram versões firmes e coesas, narrando com riqueza de detalhes a forma em que ocorreu o acompanhamento e a abordagem do réu, bem como a apreensão da droga, dispensada por ele quando da tentativa de fuga. Afirmaram que estavam muito perto do réu e viram perfeitamente quando ele dispensou a sacola com as drogas.

É fato que existe no espectro jurisprudencial, corrente, embora minoritária, que questiona a validade da prova acusatória baseada na palavra de policiais, principalmente no que diz respeito aos crimes envolvendo entorpecentes.

Tenho para mim, no entanto, que o melhor posicionamento é o que não discrimina a qualidade dos depoimentos, de sorte que a palavra do policial, que depõe sob compromisso, como testemunha, tem o mesmo valor que o de qualquer outra pessoa. Somente quando há divergências e contradições instaladas a partir do confronto de seus próprios depoimentos ou de suas declarações com os demais participantes da diligência, e essas são de tamanho relevo a determinar a imprestabilidade do testemunho, é que se deve desprezá-lo.

Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente alguém. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição.

Sobre a questão, não é dispendioso trazer à liza o escólio do Supremo Tribunal Federal: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O

depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (STF - Habeas Corpus nº 72.608-SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Com efeito, “os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP - Apelação Criminal nº 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Ora, os policiais não tinham motivos para incriminar o réu, que sequer conheciam. Portanto, a autoria delitiva está clara.

Não restam dúvidas quanto à materialidade delitiva.

O tipo penal do tráfico de drogas é misto alternativo, e a realização de qualquer conduta já é suficiente para configurar o crime. Nestes autos, ficou claro que o réu trazia consigo as drogas, sendo desnecessário ter sido flagrado em ato de venda.

Nesse sentido: Para a configuração do delito não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, transporte, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, fazendo-se, também, inexigível, a tradição, para a consumação (TJSP, Ap. Crim. 899.394/0, 6ª Câmara. Do 3º Gr. Da S. Crim., rel. Des. Marco Antonio, j. 25-10-2007, v.u., Boletim de Jurisprudência nº 136).

E, ainda que seja usuário de entorpecentes, o que não se duvida que seja, isso não descaracteriza o crime.

“O traficante pode também ser viciado e, concomitantemente, guardar ou trazer consigo para uso próprio e para a disseminação do vício; por outro lado, o viciado também pode ser instrumento de difusão do mal, quando fornece a droga a outrem. Em ambas as hipóteses acima referidas, prevalecerá o delito mais grave, ficando absorvido o delito do artigo agora comentado. Tanto no caso de um traficante que traz consigo a droga para uso próprio como no caso de alguém que, trazendo originalmente para uso próprio, vem a desviar essa destinação fornecendo-a a outrem, o bem jurídico atingido é a saúde pública em sua forma substancialmente mais grave, não podendo o que dissemina o vício beneficiar-se arguindo sua condição de usuário da droga” (“Tóxicos Prevenção Repressão”, Vicente Grecco Filho, Saraiva, 7ª edição p. 119).

As drogas apreendidas foram analisadas em perícia técnica que reconheceu a ilicitude das substâncias. O laudo do exame de constatação provisória (fls. 18/24) e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 123/125) constataram a presença das substâncias Tetrahydrocannabinol (THC) e cocaína nos materiais apreendidos.

As circunstâncias evidenciam o intuito da mercancia.

Sobreleva notar que a quantidade de droga apreendida (18,11g de cocaína em sua forma pura – pó branco de granulometria fina, 13,51g de cocaína em sua forma petrificada – crack e 64,71g de maconha), a forma de acondicionamento (a cocaína distribuída em 47 microtubos, o crack disposto em 64 pedras e a maconha fracionada em 52 porções), a quantia apreendida (R\$ 5,00, cf. fls. 50), e as circunstâncias em que ocorreram os fatos (policiais que estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram o réu em local de venda de drogas, que dispensou a sacola com drogas e empreendeu fuga), evidenciam de forma clara o intuito da mercancia.

Em que pese a primariedade do réu, nota-se que a quantidade e variedade de drogas apreendida na sacola dispensada por ele denotam que não se trata de traficante neófito, indicando sua habitualidade criminosa. Vale destacar que a primariedade do réu se dá somente pelo fato de que o trânsito em julgado de condenação por fato anterior se deu um mês após o cometimento deste crime, indicando que é dedicado a prática de crimes. Assim, não reconheço o privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Deve o réu, portanto, responder pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo à aplicação da pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu ostenta antecedentes desabonadores (processo n.º 1502638-02.2020.8.26.0625 da 3ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 119/120, cujos fatos se deram em 06 de junho de 2020 e o trânsito em julgado em 20 de julho de 2022). Deve-se, ainda, ser sopesada, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza, variedade e a quantidade de entorpecentes, a personalidade e a conduta social dos agentes. Assim, deve-se considerar a natureza deletéria de uma das drogas apreendida, cocaína em forma de pedra crack, que gera intensa e rápida dependência, acarretando condutas extremamente violentas nos casos de abstinência e que acaba empurrando os usuários a outros crimes violentos, a fim de obterem dinheiro para comprarem mais e mais drogas. Levo em conta ainda a variedade de droga apreendida (maconha, cocaína e crack), o que aumenta a culpabilidade e as consequências do delito, indicando que o réu está mais inserido no mundo do crime, lidando com diversos tipos de drogas e alcançando um número maior de usuários, evidenciando sua maior dedicação em comercializar entorpecentes, em detrimento da saúde de terceiros. Desta forma, fixo a pena-base do réu em 1/4 acima do mínimo legal, para que fique em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A exasperação da pena base mostra-se necessária em razão da natureza da droga traficada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça deste país.

Senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE EXASPERADA DE UM SEXTO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. COCAÍNA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM. 1. Mostra-se justificada a exasperação da pena-base além do mínimo legal baseada na natureza da droga apreendida - cocaína -, por se tratar de substância nociva à saúde do usuário, a teor do que preceituam os artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 2. Trata-se o artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, de norma de direito material de observância obrigatória quando da fixação da pena nos delitos por ela regulados por imperativo constitucional, eis que beneficia o agente dada a possibilidade de redução da reprimenda. 3. Faz jus à diminuição da pena o paciente que preenche todos os seus requisitos, não sendo motivação idônea para se afastar a incidência da minorante a menção no sentido de ser o paciente detentor de Maus antecedentes levando-se em conta condenação ainda não transitada em julgado. 4. Habeas corpus denegado, e concedida a ordem, de ofício, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena do paciente na ação penal de que aqui se cuida a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa” (STJ, HC 152.285/SP, Ministro Relator Haroldo Rodrigues, j. em 23/02/2010 - destaquei).

O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“A reprimenda mostrou-se adequada e motivadamente dosada: pena-base fixada em 1/5 acima do mínimo legal pelos Maus antecedentes (fls. 126 tráfico) e pela potencialidade lesiva da droga, acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 125 roubo circunstanciado), alcançando a pena final de 07 anos de reclusão; não aplicado o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, diante da reincidência. Assim sendo, e não se evidenciando erro técnico ou excessivo rigor, a punição deve ser mantida, tal como estabelecida” (14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação nº 0004327-68.2012.8.26.0292. Relator Des. Marco de Lorenzi. J. em 04/07/2013 - destaquei).

Embora o trânsito em julgado do referido processo tenha se dado posteriormente a este delito que se julga (em 20/07/2022), é plenamente cabível a valoração na primeira fase da pena, como antecedentes desabonadores, porquanto o crime foi cometido anteriormente a este, em 06/06/2020.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO

JURÍDICO. (...) 3. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. (...) 3. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal" (STJ, HC n. 210.787/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 10/09/2013).

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (...) (STJ, Resp n. 1.711.015/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018).

Em que pese não haja nos autos certidão de objeto e pé do(s) processo(s) em que o réu foi condenado, é pacífico o entendimento de que a folha de antecedentes e/ou a certidão proveniente do Cartório Distribuidor são suficientes para a caracterização dos maus antecedentes e da reincidência. É, inclusive, o entendimento do Superior tribunal de Justiça, sumulado no enunciado 636, in verbis: "a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência".

Ausentes agravantes e atenuantes.

Como já dito, em que pese a primariedade do réu, esta se dá somente pelo fato de que o trânsito em julgado de condenação por fato anterior se deu um mês após o cometimento deste crime, indicando que é dedicado a prática de crimes.

Nota-se que a quantidade e variedade de drogas apreendidas na sacola dispensada por ele denota que não se trata de traficante neófito, indicando sua habitualidade criminosa.

Sobre a utilização da quantidade e droga apreendida com o réu e presença de maus antecedentes para o não reconhecimento do tráfico privilegiado, assim entende o Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva - ausência de dedicação a atividades criminosas -, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o 'maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa'. 4. Agravo interno desprovido" (HC 210563 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 03-06-2022 PUBLIC 06-06-2022 - destaquei).

Assim, não reconheço o privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. À mingua doutras causas modificadoras da reprimenda, torno-a definitiva.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no artigo 33, §2º, alíneas "b" e §3º, do Código Penal, em razão das circunstâncias já consideradas na primeira fase da dosimetria da pena, como

natureza deletéria e maior culpabilidade, em razão da variedade de drogas traficadas, bem como pelos antecedentes criminais do réu.

A fixação de regime mais gravoso do que aquele previsto para a pena imposta é idôneo quando baseado nas circunstâncias judiciais (CP, art. 59) e levando-se em consideração, ainda, com preponderância sobre o referido dispositivo, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (Lei 11.343/06, art. 42).

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.” (AgRg no HC 513455/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019; AgInt no AREsp 1503628/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019; AgRg no AREsp 1465052/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019; HC 492114/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019; HC 499603/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/05/2019; HC 505557/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/05/2019; AgRg no RESp 1799931/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/05/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NEGATIVA DE APLICAÇÃO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, QUE NÃO É TÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. INCIDÊNCIA EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS E PRIMARIEDADE. ADEQUAÇÃO PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO ATENDIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 4. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. (...) 8. A valoração negativa da quantidade e natureza dos entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso, bem como para obstar a respectiva substituição por penas restritivas de direitos. 9. Na espécie, a razoável quantidade e a natureza especialmente deletéria da droga apreendida apenas justifica o regime intermediário, na medida em que o paciente é primário e a condenação foi reduzida para patamar que não excede 4 anos de reclusão.” (STJ, HC n. 451.496/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 06/11/2018 – destaquei). Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR JHONATAN LEONARDO DA CUNHA SOARES, filho de Sidnei Antônio Soares e Claudinea da Cunha, RG n.º 54.471.956, nascido aos 30 de agosto de 1996, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Declaro, após o trânsito em julgado, a teor do disposto no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal e no artigo 62 da Lei 11.343/06, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida em poder do réu (depósito judicial às fls. 50), porque produto do narcotráfico, devendo tal montante ser depositado em conta do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas.

Lance-se, com o trânsito em julgado, o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se

o necessário para o cumprimento da reprimenda.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA